



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 67/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בפני כב' המפקחת אסתי שחל

בעניין:

1. אייל אביגד
 2. לאה פולק
 3. בלה סמוליאנסקי
 4. ישראל סמוליאנסקי
 5. גבריאל טולמן
- ע"י ב"כ עו"ד דלית טייכמן מלול
רח' היצירה 29, רמת גן, 52521
טל': 03-6033162, פקס': 153-77-4212752

התובעים

- נ ג ד -

חנה איסלר
ע"י ב"כ עו"ד יהודית דויטשר ברקן
רח' התע"ש 8, רמת גן, 52523
טל': 03-5270766, פקס': 03-5270793

הנתבעת

פ ס ק - ד י ן

1. עניינה של התביעה מתן צו שיורה לנתבעת ו/או מי מטעמה להימנע מלבצע עבודות בניה בגג המשותף של הבית; להורות לנתבעת להשיב את גג הבית המשותף לקדמותו כפי שהיה עובר לתחילת ביצוע עבודות הבנייה על הגג לרבות סגירת הפתח אותו פערה בגג הבית המשותף; ליתן כנגד הנתבעת ו/או מי מטעמה צו עשה לניקוי כל הפסולת אשר נזרקה לרכוש המשותף כתוצאה מעבודות הבנייה, להורות לנתבעת לבצע עבודות לאיטום גג הבית המשותף; ולהשיב את הדוודים והאנטנות של בעלי הדירות למקומם המקורי.
2. המדובר בבית משותף שברחוב רבי עקיבא 11, הרצליה, הידוע כגוש 6546 חלקה 492 (להלן: "הבית"). התובעים הם חלק מבעלי זכויות החכירה בדירות בבית. הנתבעת היא בעלת זכות החכירה בדירה בבית.
3. על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מן הבית, ערכתי ביום 10.12.12 ביקור בבית, בדירת הנתבעת ובגג נשוא המחלוקת. מביקורי זה ומתשריט הבית המשותף עולה כדלקמן: הבית מכיל 4 מבנים, ובסך הכל 56 דירות. הבית בו מתגוררים התובעים והנתבעת מכיל 12 דירות, ומחולק לשתי כניסות ובכל כניסה 6 דירות. דירת הנתבעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 67/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

ממוקמת בקומה השלישית. גג הבית ממוקם מעל 2 הדירות בקומה השלישית, חציו מעל דירת הנתבעת. גג הבית אינו צמוד למי מדירות הבית, והוא מהווה רכוש משותף של כלל בעלי הדירות בבית. הגג נשוא המחלוקת הוא הגג שמעל דירתה של הנתבעת (להלן: "הגג").

טענות התביעה יפורטו להלן בתמצית

4. הנתבעת פערה פתח בגג, ובנתה גרם מדרגות אשר מוביל מדירתה לקומת הגג לצורך בניית יחידת דיור על הגג לשימושה. הפתח שנפער בגג מוביל למבנה זכוכית אותו הקימה הנתבעת, וממנו קיימת יציאה לגג. לשם כך הזיזה הנתבעת על דעתה את האנטנות והדודים של בעלי הדירות בבית, ומבלי שקיבלה הסכמתם לכך;
5. הנתבעת השתלטה על הגג גידרה אותו, ועושה בו שימוש ייחודי;
6. עבודות הבניה המבוצעות על ידי הנתבעת בגג נעשות ללא היתר, תוך השארת פסולת ולכלוך בשטחי הרכוש המשותף של הבית;
7. כתוצאה מעבודות הבניה המבוצעות על ידי הנתבעת בגג, החלה נזילה של מים בדירתו של התובע 5, ואף חדלה אספקת המים החמים לחלק מדירות הבית;
8. פניות התובעים לנתבעת להפסיק את עבודות הבניה העלו חרס.

טענות ההגנה יפורטו להלן בתמצית

9. אין לתובע 5 כל זכות עמידה אלא באמצעות הוריו שהינם אפוטרופוסיו, והוא מנוע מלתבוע ו/או להיות צד לתובענה נוכח הסכמה שנתנו הוריו לנתבעת לבנות על הגג;
10. רוב בעלי הדירות ובהם חלק מהתובעים או חליפיהם, נתנו הסכמתם לבניה על הגג לבעליה הקודמים של דירת הנתבעת עוד בשנת 99, ובהסתמך על כך, רכשה הנתבעת את דירתה;
11. על סמך ההסכמה הנ"ל הגישה הנתבעת בתחילת שנת 2002 בקשה להיתר בניה על הגג לתוספת חדר ופרגולה. בשל חסרון כיס לא עלה בידי הנתבעת להוציא את הבנייה לפועל, וכל שעלה בידה לעשות הוא לבנות פתח בתקרת דירתה לגג. לאחר הגשת התביעה חידשה הנתבעת את הבקשה להיתר לתוספת חדר ופרגולה על הגג, בהסתמך על הסכמות בעלי הדירות שניתנו לבעליה הקודמים של הדירה;
12. השימוש אותו עושה הנתבעת בגג הוא שימוש סביר לפי תנאי הזמן והמקום, נוכח העובדה כי בעלי דירות אחרים בבית אינם יכולים לעשות שימוש דומה;
13. בשל חדירת מי גשמים רבים לדירתה נאלצה הנתבעת להזיז את הדודים שבגג על מנת לבצע עבודות איטום בהסתמך על חוות דעת הנדסית. משהתברר לנתבעת כי הדוד של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 67/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

תובעים 3 ו-4, רקוב וחלוד, העבירה את הדוד שהיה ברשותה לרשות התובעים 3 ו-4 – והתקינה בו על חשבונה חמם חדש, ולעצמה רכשה דוד חדש. כמו כן, ומטעמי בטיחות התקינה הנתבעת בגג מעקה אבן היקפי ומעליו מעקה ברזל. עובר לביצוע העבודות, האמורות, והחלפת הדוד, פנתה הנתבעת לבעלי הדירות לקבל הסכמתם, אך אלה סירבו לשתף עמה פעולה;

14. לדירת התובע 5 חדרו מי גשמים כתוצאה מקריסת אנטנה בלתי שמישה ולא כתוצאה מהעבודות שבוצעו על הגג. מאחר והוריו של התובע 5 הטילו האחריות לנזילה על הנתבעת, שילמה להם הנתבעת פיצוי כספי בסך של 5,400 ₪ בתמורה להעדר תביעות מצדם כנגדה.

דיון והכרעה

טענות מקדמיות

15. מצאתי לדחות את טענת הנתבעת כי התובע 5 נעדר כשרות משפטית לתבוע בהליך שבפני מהטעם שנטענה בעלמא ולא הוכחה.

16. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת כי בינה ובין הוריו של התובע 5 הושגה הסכמה שיש בה כדי למנוע מהתובע 5 להגיש תביעה זו. בהתאם לנסח הרישום החל על הבית התובע 5 הוא הבעלים של דירה בבית. הסכמות כאלה ואחרות שהושגו בין הוריו של התובע 5 לבין הנתבעת, ביחס לדירתו של התובע 5, אין בהן כדי לחייב את התובע 5 מקום שלא הוכח כי מונה לו אפוטרופוס, כנטען. לא זו אף זו, עיון במסמך מיום 28.3.12 (צורף כנספח א' לכתב ההגנה) עליו מבססת הנתבעת את טענתה מלמד כי המדובר במסמך שעניינו "אישור וקבלת תשלום", כלשון כותרת המסמך, בסך של 5,400 ₪ כפיצוי מוסכם, אותו שילמה הנתבעת, על נזקים שנגרמו לדירת התובע 5 כתוצאה מעבודות שיפוץ שביצעה הנתבעת על הגג, ואין ללמוד ממנו הסכמה כלשהי לביצוע עבודות אלה, מצד הוריו של התובע 5, לא כל שכן מצד התובע 5.

המסגרת הנורמטיבית

17. סעיף 62 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:

"בעלי דירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (הדגשה שלי א.ש.).

18. מסעיף 62 לחוק המקרקעין עולה כי לא ניתן להצמיד חלק מסוים מן המקרקעין לדירה מסוימת ללא הסכמת כל בעלי הדירות בבית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 67/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

19. על מהות ההסכמה הדרושה ע"פ החוק ומשמעותה נתן בהמ"ש את דעתו במספר פסקי דין. ראה למשל ע"א 136/63, לוויני היס ואח' נ' שורצמן ואח', פ"ד י"ז 1726 נקבע:

"... זכות השייכת לכמה שותפים ואינה מתייחסת לעניין שימושי רגיל שכולם נהנים ממנו בדרך של שיגרה, אין אחד השותפים יכול ליטול אותה או חלק ממנה לעצמו ולהדיר את השותפים האחרים ממנה שלא בהסכמתם". ראה גם ע"א 188/76, רוזנוקס נ' הוטרר ואח', פד"י ל"א (1), 382 בע"מ 384, כן ע"א 815/81, כליפא ואח' נ' שאל ואח', פ"ד ל"ו (3), 78 בע"מ 83.

20. תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף, אף ללא שבוצעה הצמדה פורמאלית, טעונה אף היא הסכמת בעלי הדירות כאמור. במהותה דומה פעולת תפיסת החזקה הייחודית להצמדה, שכן בשני המקרים תגרום הפעולה לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות האחרים ברכוש המשותף. ראה לעניין זה ע"א 2525/92, וקרני נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5), 850:

"... משמעות הדברים היא, כי לכל אחד מבעלי הדירות זכות להתנגד לפגיעה ברכוש המשותף על ידי בנייה בו וצירופו לאחת הדירות. תפיסת חזקה בלעדית על ידי בנייה "ברכוש המשותף", המיועד לשמש את כל בעלי הדירות, שוללת לצמיתות את זכות השימוש באותו חלק מהרכוש המשותף משאר בעלי הדירות, וברור כי דבר כזה אינו יכול להיעשות אלא בהסכמתם".

21. לעומת זאת, שימוש ברכוש המשותף שאין בו משום תפיסת חזקה ייחודית, והוא בבחינת שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אינו מחייב הסכמת כל בעלי הדירות בבית, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה לעניין זה ע"א 549/73, וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח(1) 645, המ' 163/81, בודנוף נ' נציגות הבית ברחוב שחראי 14-18, ים, פ"ד לה (4), 277: "שימוש ברכוש המשותף יחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".

22. ככל שמדובר בהצמדה של חלק מהרכוש המשותף לשם הרחבת דירה, כי אז קובע סעיף 71 לחוק המקרקעין כדלקמן:

"(א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתה רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה באמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 67/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין...."

מן הכלל אל הפרט

23. ביום 10.12.12 ערכתי, כאמור, ביקור בבית, בדירת הנתבעת ובגג. מצאתי לצטט להלן את עיקרי הפרוטוקול שנערך על ידי בעקבות הביקור בבית המתארים את המצב כפי שהוא שבשטח:

"...בדירתה של הנתבעת עלינו בגרם מדרגות סיבובי אל הגג שמעל דירת הנתבעת. הכניסה לגג זה היא מתוך חור הנפער בו, והמוקף במבנה זכוכית שקוף שהיציאה ממנו היא באמצעות שתי דלתות שקופות (מכונה "חממה")."

ראיתי כי הגג שמעל דירת הנתבעת תחום בכל צדדיו. חלקו תחום בבטון ומעקה מברזל, ובחלק החוצץ בינו ובין הגג שמעל הדירה המקבילה לדירת הנתבעת הוא תחום בבטון בגובה של כ- 80 ס"מ כשמעליו קרשים מעץ. הנתבעת הפנתה את תשומת ליבי כי ניתן להרים קרשים אלה ואולם לא ראיתי כיצד אלה מורמים בפועל.

כן ראיתי בגג מספר שולחנות וכיסאות המפוזרים בכל שטח הגג. כן ראיתי פינות ישיבה, מקרר ומתקן לצליית בשר (מנגל). התרשמתי כי הנתבעת עושה שימוש ייחודי בגג שמעל דירתה, וכי לא ניתן בפועל להיכנס לחלק זה של הגג אלא מתוך דירתה שלה"

24. מהבקשה להיתר בניה שהוגשה על ידי הנתבעת בשנת 2012 עולה כי הנתבעת ביקשה היתר לבניית תוספת חדר בשטח של 22.77 מ"ר ופרגולה בשטח של 12.87 מ"ר על הגג, כשהכניסה לחדר האמור הינה מתוך גרם מדרגות מדירת הנתבעת (ראה ת'1) (להלן: "הבקשה להיתר" או "הבקשה להיתר משנת 2012"). ואולם, מהתרשמותי בביקור בבית, כעולה מהפרוטוקול הנ"ל, שוכנעתי כי השימוש בו עושה הנתבעת בגג הוא שימוש ייחודי בכל שטח הגג המשותף שמעל דירתה, הרבה מעבר להקמת חדר ופרגולה, והוא אינו עולה בקנה אחד עם הבקשה להיתר.

25. גם מחקירתה הנגדית של הנתבעת התרשמתי כי הנתבעת עושה בגג שימוש ייחודי, ורואה בו שטח פרטי שלה, כאילו כלל לא מדובר ברכוש משותף:

ראה פרוטוקול מיום 11.7.12, עמ' 10, שורות 35-38: "ש.... את יכולה לתאר מה זה ת. זה קרשים מעץ ששמתי אותם כדי שאנשים לא ישוטטו לי על הגג (הדגשה א.ש.)...."

עמ' שורות 43-45, עמ' 11, שורה 3-1: "ש. חוץ ממך ומבני ביתך יכולים להסתובב על הגג ת. האורחים שלי, חבריי ש. את יכולה פחות או יותר להעריך מה הגודל של המתחם שסיפחת לעצמך ת. כגודל הדירה שלי בערך 87 מ"ר ש. את עולה לגג מהדירה שלך מהמדרגות שנמצאות בדירתך ת. נכון

עמ' 11, שורות 35-39: "היום כל שטח הגג מסופח לדירתך ת. הוא בשימוש הדירה שלי ש. רק את יכולה להשתמש בזה ת. אם השכנים היו ביחסים סבירים איתי הייתי מזמינה אותם גם להשתמש, אבל לא כך היחסים ולכן הם לא מוזמנים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 67/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

עמ' 12, שורות 35-36: "ש. מה הגדר הזו שחוצצת בין הגג שלך ת. אמרתי שכדי שלא אראה את דודי השמש שאני יושבת עם בן זוגי ואורחי על הגג".

26. מביקורי במקום, ראיתי כי הגג תחום במלוא היקפו, על ידי גדר שהקימה הנתבעת (ראה פרוטוקול ביקור במקום לעיל), וכי הכניסה היחידה אליו היא מתוך דירת הנתבעת. מתשריט הבית המשותף עולה כי קיימת כניסה אל הגג המשותף דרך פתח כוות אדם, אך בעטיה של הגדר שהקימה הנתבעת נמנעת הכניסה אל הגג המצוי מעל דירת הנתבעת. בנסיבות אלה, נמנע מן התובעים ושאר בעלי הדירות בבית מלממש את זכותם לנגישות לכל חלקי הרכוש המשותף, כמו גם הזכות לעשות שימוש סביר בגג. הנתבעת אמנם טענה כי חלקו של המעקה שהקימה בחלק החוצץ שבין הגג שמעל דירתה לגג שמעל הדירה המקבילה לה, עשוי מקרשים הניתנים לפירוק, כך שקיימת גישה אל כל הגג, אך במהלך ביקורי במקום לא התרשמתי כי כך הם פני הדברים, ומכל מקום לא יעלה על הדעת כי בכל פעם שבעל דירה ירצה להיכנס לגג, יאלץ לפרק קרשים מעץ או לסלק מכשולים.

27. לא שוכנעתי כי העבודות שביצעה הנתבעת בגג נועדו לצורך איטומו בלבד. כך גם לא שוכנעתי כי הנתבעת גידרה את הגג לצורך בטיחות בלבד. נראה כי הנתבעת ביקשה להכשיר הגג לשימושה הייחודי, תוך שהיא רואה בו קניינה הפרטי. תימוכין לכך מצאתי בעדותה של הנתבעת: "ש. האם כל השיפוץ שעשית הייתה מטרתו לטפל בבעיות האיטום. ת. בעיקר, מתוך מגמה בהמשך לבנות חדר על הגג. אני קניתי את הדירה עם חתימות של הדיירים מתוך רצון שלי לבנות על הגג". (פרוטוקול מיום 11.7.12, עמ' 12, שורות 29-31).

28. יתירה מכך, בהינתן כי הדוודים שעל הגג הינם בבעלותם של בעלי הדירות, לא הייתה רשאית הנתבעת לעשות דין לעצמה ולפעול להזזתם, לא כל שכן שלא הייתה רשאית להחליפם באחרים, ללא קבלת הסכמה מפורשת של בעלי הדירות הרלבנטיים. מעדותן של התובעות 2 ו-3, שהיו אמינות עלי, שוכנעתי כי הנתבעת כלל לא פנתה אליהן לצורך קבלת הסכמתן להזזת הדוודים או להחלפתם, והחליטה לעשות כן על דעת עצמה בלבד. (ראה עדותה של התובעת 3, פרוטוקול מיום 11.7.12, עמ' 8, שורות 24-25, ועדותה של התובעת 2, עמ' 10, שורות 7-9).

29. ממכלול הראיות שהובאו בפני ואשר פורטו לעיל, ומהתרשמותי בעת ביקורי, ובהתחשב בשימוש הייחודי אותו עושה הנתבעת בגג, אין לראות בשימוש אותו עושה הנתבעת בגג כשימוש סביר לפי תנאי הזמן והמקום, ואני דוחה מכל וכל את טענת הנתבעת בהקשר זה. מצאתי את הגג נחזה להיות גג פרטי של הנתבעת, המשמש אותה באופן קבוע, והוא כשטח שלנתבעת חזקה ייחודית בו, והיא אף רואה בו כאילו היה קנייני הפרטי.

30. המשמעות המעשית היא שהנתבעת הצמידה בפועל את הגג לדירתה. הצמדה שכזו, לא ניתן לבצע ללא הסכמת כל 56 בעלי הדירות בבית, ואין חולק שזו לא ניתנה.

31. גם לא שוכנעתי כי יש בידי הנתבעת הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירתה בהתאם לבקשה להיתר הבניה שהוגשה על ידה, ת'1, מהנימוקים שיפורטו להלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 67/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

32. מלשון החוק בסעיף 71ב(א) עולה כי לשם הרחבת דיור צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים: האחד, שלושה רבעים מבעלי הדירות בבית מסכימים להרחבה. השני, לדירותיהם של שלושת הרבעים צמודים שני שלישים מהרכוש המשותף.

33. לטענת הנתבעת יש בידה את הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירתה כדלקמן:

(א) 33 בעלי זכויות החכירה בדירות בבית חתמו על הבקשה להיתר משנת 2012;

(ב) 8 בעלי זכויות החכירה בבית סירבו לחתום ואולם הרחיבו בעצמם את דירתם, כך שיש לראותם כמי שמסכימים להרחבת דירתה של הנתבעת בהתאם לסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין לעיל;

(ג) התובע 5 חתם על הבקשה להיתר שהוגשה על ידי הנתבעת בשנת 2002, וכן על מסמך מיום 4.7.99, בו הוא מאשר לבעליה הקודמים של דירת הנתבעת (ה"ה בן עמי) לבנות על הגג, ומשכך יש לראותו כמי שמסכים להרחבה;

(ד) בעל זכות החכירה בדירה בבית המזוהה כחלקת משנה 56 (להלן: "פלומבו") חתם על הבקשה להיתר משנת 2002, ולכן יש לראותו כמי שמסכים אף הוא להרחבה בהתאם לבקשה להיתר שהוגשה בשנת 2012, בהיותה זהה לבקשה להיתר משנת 2002;

(ה) בעל זכות החכירה בדירה בבית המזוהה כחלקת משנה 45 חתם אף הוא על המסמך משנת 1999 (להלן: "פולק"), ובו הוא מאשר לבעליה הקודמים של דירת הנתבעים לבנות על הגג, ומשכך יש אף לראותו כמי שמסכים להרחבה.

הרחבה דומה

34. בעש"א (חי) 22123-10-10, **חדד נ' זינגר**, (פורסם במאגר המשפטי "נבו") דן בית המשפט בסוגיית הרחבה דומה מהי? וקבע כדלקמן:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב את דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש קריטריון בלעדי.

עצם העובדה שהרחבה שמבקש דייר לבצע ייעודה למגורים, כמו גם ההרחבה שבוצעה על ידי דיירים נוספים בבניין, אין די בה כדי לעמוד בהוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין באשר כל בניית הרחבה המבוצעת בדירה, בין אם מדובר במרפסת, בניצול שטח חדר



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 67/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

מדרגות, מחסן ועוד, נועדה בסופו של דבר להרחבת שטח המגורים. יוצא אפוא, כי מידת הדמיון או השוני בין ההרחבות אינה יכולה להיגזר מעצם ייעודם למגורים.

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב (ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבה דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין אין מקום להכשירה".

*** ראה גם ע"א (י"ם) 3235/02, אביב נ' גדולטר, (פורסם באתר המשפטי "נבו").

35. הנטל להוכיח כי עניין לנו בהרחבה דומה, בהתאם לקריטריונים שנקבעו, כמפורט לעיל, מוטל על בעל הדין הטוען לכך, ובמקרה שבפני על הנתבעת. העובדה כי על גבי הבקשה להיתר משנת 2012 צוין בצד 8 מבעלי זכויות החכירה כי הרחיבו דירתם בעבר, אין בה כדי להרים את נטל ההוכחה. בסיכומיה טענה הנתבעת כי שטחן של הדירות שהורחבו בהתאם לנסח הרישום עומד על כ - 50 מ"ר בעוד שבפועל עומד שטחן על 90 מ"ר, ויש בכך כדי להוכיח כי ביחס לדירות אלה בוצעה הרחבה. אין בידי לקבל טענה זו. ראשית, לא הוכח מהו שטחן בפועל של הדירות שביחס אליהן נטען כי הרחיבו "הרחבה דומה". שנית, אין מקום לפרש את המונח "הרחבה דומה" על פי קריטריון בלעדי של שטח שנוסף לדירה. שלישית, שטחה של דירת הנתבעת בהתאם לנסח הרישום עומד על 42 מ"ר, ואילו בחקירתה הנגדית העידה הנתבעת כי שטח דירתה בפועל עומד על כ - 87 מ"ר (פרוטוקול מיום 11.7.12, עמ' 11, שורה 1) כך שאפילו הייתי מקבלת את גישת הנתבעת, ולפיה קריטריון השטח לבדו מכריע, הרי שהיינו מוצאים כי דירתה של הנתבעת הורחבה בעבר, וכבר מיצתה זכותה לטעון להרחבה דומה.

36. נוכח כל האמור לעיל, לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת כי ביחס ל - 8 דירות בבית בוצעה הרחבה דומה, ועל כן לא מצאתי לראותם מסכימים מכוח סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין.

37. יוצא אפוא כי גם אם נקבל את טענת הנתבעת כי יש בידיה הסכמות של 33 בעלי זכויות חכירה בדירות בבית, וגם אם נקבל את טענת הנתבעת כי יש לראות בתובע 5 ובבעלי זכויות החכירה בדירות המזוהות כחלקות משנה 55 ו - 45 כמי שמסכימים להרחבה, אזי יש בידיה, לכל היותר, 36 בעלי זכויות חכירה שמסכימים להרחבה, המהווים פחות מ - 75% מבעלי הזכויות בבית, כפי הנדרש על פי חוק המקרקעין לצורך הרחבת הדירה. מכאן, שלא מתקיים התנאי הראשון לשם הרחבת דירה בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין. די היה לי בכך כדי לסיים פרק זה, ולקבוע כי אין בידי הנתבעת הרוב הדרוש לביצוע הרחבה בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, ואולם מצאתי, למעלה מן הדרוש, להוסיף את הדברים הבאים:

38. ההסכמה לבנייה על הגג בהתאם לטופס ההסכמות משנת 1999 ניתנה לבעליה הקודמים של דירת הנתבעת, ה"ה בן עמי, ולא לנתבעת. בע"א (ת"א) 271/85, הילמן צביה נ' בנימין רוזן ואח', פ"מ תשמ"ז (1), 283 נקבע כי "רשות הדירה או בלתי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 67/12

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הדירה, לעולם אינה מקנה לבעל הרשות, זכות קניינית בקרקע נשוא הרשות והיא באה לקיצה כשבר הרשות מעביר בעלותו והחזקתו בקרקע לאחר". יוצא אפוא, כי הרשות שניתנה לה"ה בן עמי לבנות על הגג היא רשות אישית והדירה והיא באה לקיצה עת הועברה הבעלות בדירה לידי הנתבעת, ואין היא מחייבת עוד את נותני הרשות כלפי הנתבעת.

39. בפרשת הילמן לעיל נקבע עוד כדלקמן: "בעניין ביטולה של רשות, יש להבחין בין רשות שעניינה עשיית פעולות שטבען להיות נטענות כגון לטייל בגן, להשתמש במעבר, לטבול בברכה וכדומה, שביטולם אינו גורר אחריו הרעת המצב שבו ברשות היה נתון בו לפני מתן הרשות, ובין רשות שעניינה הקמת מבנים של קבע וכיוצא בהם הכרוכים בהוצאות מרובות על ידי אדם המשתמש ברשות, כך שאם אחרי הקמת המבנים, נותן הרשות חוזר בו ממנה, נמצא הראשון לקה בנזק כבד, במקרה אחרון זה, דיני היושר מונעים מנותן הרשות ואף אלה הבאים מכוחו... לבטל את הרשות בלא כלום וככל העולה על ליבו".

במקרה שלפני לא נטען וממילא לא הוכח כי התובע 5 ופלומו לא היו רשאים לחזור בהם מהסכמתם, וכי מתקיימים התנאים המונעים מהם לעשות כן, כמפורט בפרשת הילמן לעיל.

40. מר איל אביגד, התובע 1, העיד בתצהירו (סעיף 12) כי חלק מ – 33 בעלי זכויות החכירה החתומים, לכאורה, על הבקשה להיתר, כלל אינם מסכימים לבניה ועל מנת לתמוך בטענתו זו צירף מסמך מיום 17.6.12 (נספח ג' לתצהירו) החתום, בין היתר, על ידי בעלי זכויות החכירה בחלקות משנה 39, 33, 14, 40 ו - 36, בו הם מביעים את התנגדותם "לאישור היתר בניה אשר הוגש ע"י הגב' חנה איסלר". גם ביחס לבעלי זכויות חכירה אלה לא טענה הנתבעת וממילא לא הוכיחה כי הם לא היו רשאים לחזור בהם מהסכמתם, וכי מתקיימים התנאים המונעים מהם לעשות כן, כמפורט בפרשת הילמן לעיל.

41. הנה כי כן, ונוכח כל האמור לעיל, המסקנה המתבקשת היא כי הנתבעת לא הרימה את הנטל להוכיח כי בידה הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירתה בהתאם לסעיף 71 לחוק המקרקעין.

42. לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעת בסיכומיה כי פעירת הפתח מדירתה לגג ובניית מבנה הזכוכית הקיים עליו, נעשתה כדין ובהסתמך על הבקשה להיתר בניה משנת 2002. לא הוכח כי ניתן לגבי מבנה זה היתר כדין. גם לא הוכח כי יש בידי הנתבעת הרוב הדרוש לכך. עיון בבקשה להיתר משנת 2002, מלמד כי התבקשה בניית חדר ופרגולה וזאת בשונה מהמבנה הזכוכית אשר נבנה בפועל, וכי חתומים עליה לכל היותר 9 בעלי זכויות חכירה, כך שגם אם נראה במבנה זה "הרחבת דירה", וספק אם כך הדבר, הרי שאין בידי הנתבעת את הרוב הדרוש לכך בהתאם לסעיף 71 לחוק המקרקעין.

יתר הסעדים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 67/12

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

43. טענת התובעים כי הנתבעת השליכה פסולת לרכוש המשותף שהצטברה כתוצאה מעבודות הבניה לא הוכחה, ועל כן, לא מצאתי ליתן לתובעים את הסעד שהתבקש בהקשר זה.

44. לא הובאה כל ראיה על מנת לתמוך בטענה כי בדירת התובע 5 קיימת נזילה פעילה, ומשכך לא מצאתי ליתן לתובעים את הסעד שהתבקש בהקשר זה.

45. טענת התובעים כי במסגרת העבודות שביצעה הנתבעת בגג הוזזו האנטנות לא הוכחה, ומשכך לא מצאתי ליתן לתובעים את הסעד שהתבקש בהקשר זה.

46. אשר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה בחלקה, ומורה לנתבעת ו/או מי מטעמה כדלקמן:

א. להימנע מלבצע עבודות בניה בגג המשותף של הבית.

ב. להשיב, בתוך 60 ימים ממועד מתן פסק הדין, את גג הבית המשותף לקדמותו כפי שהיה עובר לתחילת ביצוע עבודות הבניה על הגג, לרבות סגירת הפתח אותו פערה בגג הבית המשותף, וכן סילוק כל הבנוי וסילוק כל הפסולת שתיוצר כתוצאה מכך, והכל על חשבונה של הנתבעת.

ג. להשיב, בתוך 60 ימים ממועד מתן פסק הדין, את הדוודים של בעלי הדירות למקומם המקורי, ולבצע איטום של הגג במקומות בו עמדו הדוודים טרם הפירוק בד בבד עם השבת הדוודים, כאמור, וזאת על חשבונה של הנתבעת. למען הסר ספק, רק לאחר שימצא כי הדוודים תקינים, ופועלים כנדרש, תמצא הנתבעת כמי שמילאה אחר הוראתי זו.

ד. כן תשלם הנתבעת לתובע שכר טרחת עורך דין בסך של 7,000 ₪, וכן סך של 633 ₪ עבור האגרה ששולמה בתיק. סכומים אלה ישולמו בתוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית ממועד מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום י"ט בטבת תשע"ד, 22 בדצמבר 2013. עותק יומצא.

אסתי שחל

מפקחת על רישום מקרקעין, נתניה